



论人格权请求权与侵权损害赔偿请求权的分离

王利明^{*}

内容提要 人格权独立成编是我国民法典体例的重大创新,在独立成编的人格权法中是否应当规定人格权请求权,以及如何规定人格权请求权,是我国人格权立法需要解决的重大疑难问题。笔者认为,人格权请求权的独立性是其与侵权损害赔偿请求权分离的基础,人格权请求权的产生与发展是人格权制度重要的发展趋势;人格权请求权与侵权损害赔偿请求权的区别是二者分离的原因;充分有效保护人格权是人格权请求权与侵权损害赔偿请求权分离的目的。笔者并对民法典草案中有关人格权请求权与侵权损害赔偿请求权分离模式的立法选择作出了探讨。

关键词 人格权请求权 侵权损害赔偿请求权 民法典制定

DOI:10.14111/j.cnki.zgxf.20190107.001

所谓人格权请求权,是指民事主体在其人格权受到侵害、妨害或者有妨害之虞时,有权向加害人或者人民法院请求加害人承担停止侵害、排除妨害、消除危险、恢复名誉、赔礼道歉等责任,以恢复人格权的圆满状态的权利。但我国《侵权责任法》采用“大侵权模式”,该法第15条规定了多种侵权责任形式,其中包括了人格权请求权,此种模式可称之为“吸收模式”,即在侵权请求权中吸收人格权请求权。正因为这一原因,在人格权立法过程中,关于是否存在独立的人格权请求权,存在不同观点。笔者认为,在我国民法典制定中,有必要在侵权责任编中继续保留“大侵权模式”,同时在人格权编中对人格权请求权作出系统规定,使人格权请求权与侵权损害赔偿请求权相分离,此种模式可称之为“分离模式”。是否采纳此种“分离模式”是人格权能否独立成编的关键和核心问题,而对“分离模式”的采用也是区分人格权编与侵权责任编的重要基础。我国民法典草案一审稿第778条已经在人格权编中对人格权请求权作出了规定,^①但这一规定的理论基础以及人格权请求权与侵权损害赔偿请求权的区别仍然值得深入探讨。笔者不揣浅陋,拟就此谈一点看法。

^{*} 中国人民大学教授,中国人民大学民商事法律科学研究中心研究员。本文系国家社科基金重大项目“人格权立法研究”(项目批准号:18ZDA143)的阶段性成果。

^① 民法典草案一审稿第778条第1规定“侵害民事主体人格权的,应当依照本法和其他法律的规定承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔偿损失、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉等民事责任。”





一、人格权请求权的独立性是 其与侵权损害赔偿请求权分离的基础

在民法中,基础性的民事权利都有相应的请求权,并因基础权利的功能差异而各自独立,物权请求权与债权请求权的区隔就是适例。人格权不同于其他民事权利,人格权请求权因此也具有独立性。具体说来,人格权是绝对权,具有支配性和排他性,这一点与物权、知识产权等绝对权无异。基于人格权,权利人对其人格利益享有支配的权能,并可以对抗第三人,只要权利人对其人格利益的圆满支配状态受到了不法侵害,其都有权提出相关请求,以恢复此种圆满支配状态,而且,权利人在提出此种请求时,不以行为人的行为构成侵权为前提。正如拉伦茨指出的,人格权请求权使人格权主体能够排除行为人的不法侵害行为,以恢复人格权的圆满状态。^②尤其是,与其他绝对权一样,人格权不仅具有积极行使的功能,而且具有保护人格权权能的消极效力。这就是说,当人格权的行使受到不当妨害时,权利人有权依据人格权请求权请求行为人停止侵害、排除妨害、消除危险,以维护人格权的圆满支配状态。可见,人格权请求权也正是人格权消极效力的具体体现,在保护人格权方面具有独特的功能。一言以蔽之,作为保护人格利益的绝对权,人格权和其他绝对权一样,也具有自身独立的请求权。^③

上述认识在比较法上也有先例可循。《瑞士民法典》最早规定了人格权的一般保护规则,开创了人格权请求权的先河,该法典第28a条规定“原告可以向法官申请:(1)禁止即将面临的侵害行为;(2)除去已经发生的侵害行为……”。根据瑞士学者的解释,《瑞士民法典》和《瑞士债法》规定了两种不同类型的人格权诉讼,确立了绝对权请求权诉讼与侵权诉讼并列的二元诉讼模式^④。一是防御性诉讼,即由《瑞士民法典》第28a条第1款规定的三类防御性诉讼,包括妨害预防诉讼(即对即将发生的、对人格权的不法妨害而提起的诉讼)、妨害排除诉讼(即针对正在持续的不法妨害行为而提起的诉讼)以及确认权利之诉(即针对侵害行为虽已结束但造成损害仍未完全消除,权利人所提起的请求确认侵害行为不法性的诉讼)。二是损害赔偿诉讼,即针对人格权遭受侵害所遭受的损失所提起的诉讼,此类诉讼由《瑞士债法典》第41条(侵权一般条款)和第49条(侵害人格权)所规定。损害赔偿诉讼既包括财产损害赔偿诉讼、精神损害赔偿诉讼,还包括返还侵权得利诉讼。^⑤由此可见,在瑞士法中,人格权请求权与包括侵权损害赔偿请求权在内的其他请求权是相分离的。

其他大陆法国家民法虽然没有规定人格权请求权,而主要通过侵权法规则来保护

② 参见 [德] 卡尔·拉伦茨《德国民法通论》(上册),谢怀栻等译,法律出版社2004年版,第326-328页。

③ Vgl. MüKoBGB/ Rixecker BGB, § 12 Anh. Rn. 58 ff.

④ See Olivier Guillod, Droit des personnes, 4e édition, Basel: Helbing Lichtenhahn, 2015, p. 135-143.

⑤ 参见石佳友《人格权立法的历史演进及其趋势》,载《中国政法大学学报》2018年第4期。





人格权,但这种立法模式已不足以应对实际需求,各国不得不通过司法来创设人格权请求权。比如,德国法院认为,物权以外的其他绝对权,由于缺少类似于物权请求权的保护方法,存在一项立法的漏洞,因此,基于正义的要求,司法实践中的法官法在一定程度上填补了这一漏洞,即通过整体地类推适用《德国民法典》第 12 条、第 862 条、第 1004 条,承认排除妨碍和消除危险请求权,以对抗那些仅仅在客观上不法的对受法律保护的权利的侵害。^⑥ 2005 年 10 月 25 日,德国联邦宪法法院发布裁定,明确指出,针对一项损害他人名誉的言论,应当适用不作为请求权保护一般人格权,其规范基础是民法典第 1004 条第 1 款、第 823 条第 2 款以及刑法典第 186 条。^⑦ 法国法并没有在立法中明确规定人格权请求权,但在 1970 年《法国民法典》修订时增加了第 9 条规定“每个人均享有其私生活受到尊重的权利。”基于这一规定,法国法院对于侵害私生活受尊重权利的民事责任的构成要件进行了明确。法国最高法院在判决中确认,该条独立于第 1382 条规定的侵权责任,构成一项独立的诉讼,不需要过错等要件。法国最高法院在 1996 年 11 月 5 日的一个著名判例中指出“根据民法典第 9 条,证实损害的存在就足以授予受害人以赔偿”^⑧;这就是说,对他人私生活一切任意性的干涉都是非法的,对他人私生活的不法调查应受到法律制裁。有论者指出,这是对主张侵权责任一般原则吸收民法典第 9 条论点的彻底推翻^⑨。正是通过对私生活受保护的解释,法国法逐渐形成了不同于民法典第 1382 条过错侵权责任的特殊构成要件,从而也表明了人格权请求权的特殊性。日本民法虽然也没有在立法中承认人格权请求权,但日本最高法院在“北方杂志案”的判决中明确指出:名誉遭受违法侵害者,除可要求损害赔偿及恢复名誉外,对于作为人格权的名誉权,出于排除现实进行的侵害行为或预防将来会发生的侵害的目的,应解释为还可以要求加害者停止侵害。可见,日本法上在名誉权遭受侵害的情况下,权利人除可以要求损害赔偿及恢复名誉外,对于现实的侵害行为和将来可能发生的侵害行为,权利人还可以请求行为人停止侵害。^⑩ 此外,日本的学说总体上也倾向于支持本国法院的判例,承认人格权请求权具有独立性,否认侵权请求权包括停止行为请求权。^⑪

我国现行法没有单独规定人格权请求权,在人格权遭受侵害的情形下,现行立法主要通过侵权请求权对权利人提供救济。《侵权责任法》第 15 条规定采用了“吸收模式”,此种模式的优点是:在一定程度上便利当事人同时利用多种责任形式实现对权利的全面救济,并可以通过一次侵权诉讼同时解决损害赔偿和权利的防御性保护问题。但是,此种模式没有区分绝对权请求权和侵权损害赔偿请求权,在人格权保护领域,此

⑥ Vgl. BeckOGK/Spohnheimer BGB, Aufl. ,2017, § 1004 Rn. 13.

⑦ Vgl. BVerfG NJW 2006, 207, 208.

⑧ Cass. Civ. 1ère, le 5 novembre 1996, in Bulletin Civil, I, n°378.

⑨ Cass. Civ. 1ère, le 25 février 1997, in JCP, G., 1997, II, p.22783, note J. Ravanans.

⑩ 参见姚辉《民法上的“停止侵害请求权”——从两个日本判例看人格权保护》,载法苑精萃编辑委员会编《中国民法学精萃》(2003 年卷),机械工业出版社 2004 年版,第 578-580 页。

⑪ 参见杨立新《人格权法》,中国法制出版社 2006 年版,第 63 页。





种模式也即没有区分人格权请求权与侵权损害赔偿请求权。然而,无论从人格权自身的特点来看,还是从域外立法经验来看,人格权请求权都具有独立性,这种独立性表现在:第一,人格权请求权依附于人格权,是基于人格权效力而产生的人格权独有的保护方式。只要人格权确定存在,人格权请求权即随之产生,一旦人格权的行使受到或者可能受到妨碍,无论是否构成侵权,权利人都可以主张人格权请求权;人格权请求权附随于人格权,具有强烈的人身专属性,不能与人格权相分离而独立存在,只能由人格权主体享有,权利人不能将其单独转让或者允许他人继承;权利人死亡时,人格权请求权也一并消灭。^⑫第二,人格权请求权的功能具有独立性。侵权损害赔偿请求权的主要功能是损害填补和损害预防,人格权请求权虽然也具有损害预防的功能,但其主要功能在于维护权利人对其人格利益的圆满支配状态。第三,人格权请求权的适用条件具有独特性,尤其是其适用不以行为构成侵权为条件^⑬,即使在没有构成侵权的情形下,只要是妨害了人格权或者可能妨害人格权,权利人都可以行使人格权请求权。第四,人格权请求权的适用对象具有特殊性。人格权请求权适用于各种妨害人格权或者可能妨害人格权的行为,不论此类行为是否造成了现实的损害后果,权利人都有权主张人格权请求权。正因如此,人格权请求权不能被包括侵权损害赔偿请求权在内的其他请求权所包含,这是其与侵权损害赔偿请求权分离的基础。

二、人格权请求权与侵权损害赔偿请求权的区别是 其二者分离的原因

人格权请求权是基于人格权的效力而产生的,是对作为绝对权的人格权进行保护的特有方法。人格权因侵权行为而受损害,受害人也可以请求侵权损害赔偿,包括财产损害赔偿和精神损害赔偿。从性质上看,侵权损害赔偿请求权适用于所有的侵权案件,它不是基于绝对权的效力而产生的,其本身具有债权的性质。我国民法典草案一审稿侵权责任编对侵权责任归责原则的表述使用了“损害”的概念^⑭,表明其归责原则主要是损害赔偿的归责原则,而不是各种侵权责任形式的归责原则,侵权责任编所规定的过错责任,只是针对侵权损害赔偿请求权而言的。^⑮对损害赔偿之外的责任形式,如停止侵害、排除妨碍、消除危险等请求权而言,并不当然适用过错归责原则,这也为区分侵权损害赔偿请求权与人格权请求权等其他绝对权请求权提供了依据。

侵权损害赔偿请求权是针对所有民事权益的救济方法,也就是说,任何民事权益因侵权而遭受损害,受害人都可以主张侵权损害赔偿请求权。但是人格权请求权则是专

^⑫ Vgl. Jauernig/Teichmann BGB, § 823 Rn. 64 ff.

^⑬ 参见王泽鉴《人格权法:法释义学、比较法、案例研究》,北京大学出版社2013年版,第387页。

^⑭ 民法典草案一审稿第945条规定“行为人损害他人民事权益,不论行为有无过错,法律规定应当承担侵权责任的,依照其规定。”

^⑮ 参见程啸《侵权责任法》(第2版),法律出版社2015年版,第85页。





门针对人格权的救济方法。在人格权遭受侵害后,人格权请求权的作用在于恢复人格权的圆满状态,而不是为了填补权利人的实际损害。正是因为人格权具有特殊性,所以要恢复其圆满状态,就必然要采取与救济财产权不同的救济方式。

通常,侵害人格权的损害赔偿不同于侵害物权等财产权的损害赔偿,难以通过损害赔偿的一般规则(即“差额说”)来界定人格权被侵害时受害人所遭受的损害。尤其应当看到,在人格权遭受侵害的情形下,侵权损害赔偿不能对受害人提供充分的救济:损害赔偿是一种事后救济,而且对精神利益的侵害,仅仅通过金钱的支付可能难以实现有效补救。而恢复名誉、消除影响、赔礼道歉等方式,在救济精神损害方面可能比金钱赔偿更为有效。早在一百多年前,德国学者耶林曾经抨击了罗马法中赔偿制度广泛采用的不合理性:当损害难以举证,或受害人提起诉讼不是为了获得金钱利益而是“为了主张人格本身及其法感情这一理想目的”时,盲目采用损害赔偿则无助于对权利的充分保护。^{①⑥}此外,还要看到,在人格权遭受侵害的情形,受害人往往难以证明损害的具体程度和数额,甚至难以证明遭受了现实的损害。例如,在未经许可擅自利用他人的肖像、无正当理由拒绝他人的姓名变更请求、个人信息记录不准确、个人信息被不当共享等情形中,权利人往往难以证明其遭受了何种损害。这些情形都表明,在遭受侵害的情形下,人格权具有不同于财产权的特殊救济方式,这就是人格权请求权。

具体而言,人格权请求权与侵权损害赔偿请求权的区别主要体现在:

第一,是否考虑过错不同。侵权损害赔偿责任的成立需要行为人主观上存在一定的过错。侵权损害赔偿也是救济人格权的重要方法,但此种责任形式在构成要件上原则上要求满足过错要件,以保障一般行为自由,实现行为的可预期性。而人格权请求权在性质上属于绝对权请求权,绝对权请求权的目的都在于恢复个人对其绝对权利利益的圆满支配状态,人格权请求权也不例外,因此该请求权的行使并不要求行为人具有过错。正如《瑞士民法典》起草人胡贝尔教授在解释该法所设立的人格权请求权制度时指出的,妨害排除诉讼的目的就在于排除妨害行为,而不考虑行为人是否存有过错。^{①⑦}比较法上的司法实践经验也可证明这一点,例如,在德国法中,排除妨碍并不需要直接证明妨碍人具有主观上的过错,只要妨碍人格权益等绝对权益的事由是客观存在的,就可以基于第 1004 条请求排除对权利人所带来的实体以及精神上的影响;^{①⑧}根据法国最高法院的判例,请求排除对隐私权的侵害同样不要求过错的存在^{①⑨}。我国《侵权责任法》第 6 条第 1 款规定了过错责任的归责原则,但事实上,这一归责原则很难适用于停止侵害、排除妨害等责任形式,其适用对象主要是侵权损害赔偿。由此可见,在人格权遭受侵害或者有遭受侵害的危险时,赋予权利人人格权请求权,并且不考虑行为人是否具有过错,有利于防止损害的发生或者扩大,更有利于人格权的保护。也就是说,只要行为

^{①⑥} 参见耶林《为权利而斗争》,载梁慧星主编《民商法论丛》(第 2 卷),法律出版社 1994 年版,第 21 页。

^{①⑦} 参见前引⑤,石佳友文。

^{①⑧} Vgl. BGH NJW 2011,1005; BGH BeckRS 2011,4947.

^{①⑨} Cass. Civ. 1^{ère}, le 5 novembre 1996, *Op. cit.* 8.





论人格权请求权与侵权损害赔偿请求权的分离

人的行为影响到了权利人对其人格利益的圆满支配状态,权利人即有权主张人格权请求权,以消除相关的危险或者制止不法侵害行为,而不需要证明行为人主观上具有过错,这显然更有利于减轻权利人的举证负担。

第二,是否具有对人格权侵害的预防功能不同。在瑞士法中,人格权请求权被纳入到防御性诉讼中(actions défensives),就是因为人格权请求权具有损害预防功能。侵权损害赔偿主要是一种事后的救济,是在各种绝对权遭受侵害的情况下对受害人的事后补救。而人格权请求权并不完全侧重于对损害的事后救济,而主要侧重于对损害的事先预防:一方面,在行为人妨害他人人格权但不构成侵权时,权利人虽无法主张侵权损害赔偿请求权,但仍然可以主张人格权请求权,在此情形下,人格权请求权就可以发挥损害预防的功能;另一方面,人格权请求权包含了各种责任形式,就停止侵害、消除危险等预防性的侵权责任形式而言,其本身可以起到预防的作用。因为许多人格权一旦遭受侵害,其损害后果具有不可逆转性,很难恢复到如同损害没有发生的状态(例如,某个名人的隐私照片被公布,就不能再恢复到受侵害以前的状态),所以,许多学者认为,人格权的保护要注重“防患于未然”^②。此外,还应该看到,按照传统观点,人格权在性质上属于消极防御性的权利,只有在遭受侵害时,权利人才能主张权利,而人格权请求权则具有积极主动的特点,尤其是随着个人信息保护、隐私保护等的发展,人格权请求权主动的特点更有利于有效地维护人格权的完整性。例如,在隐私和个人信息权受侵害时,受害人有权要求采取更正、删除、封锁、补充等措施,以保护其权利。可见,侵权损害赔偿制度侧重于提供事后的救济,其一般以发生实际损害为前提,而人格权请求权制度则更注重事前的预防,其不以损害的实际发生为前提,而仅需要人格权受到妨害或者有受到妨害的可能。

第三,是否要求证明实际损害不同。在法律上之所以确认人格权请求权,一方面是因为在人格权遭受侵害的情形下,受害人往往面临损害举证的困难,或者难以确定损害的具体数额,必须寻求侵权损害赔偿责任之外的救济方式;另一方面,在妨害人格权行使的情形下,虽然没有发生实际损害,但通过允许权利人行使人格权请求权,有利于制止损害的发生,从而达到“防患于未然”的目的。正是因为上述原因,人格权请求权的行使并不要求损害已经实际发生:在人格权益有遭受损害之虞时,权利人即可以要求行为人消除危险;而当侵害行为正在进行时,虽然侵害结果还没有发生,权利人也可以要求行为人排除妨害。而由于侵权损害赔偿之债以填补受害人实际损害为主要目的,因此,其适用需要受害人证明其遭受了实际损害。可见,人格权请求权与损害赔偿请求权在是否要求证明实际损害方面存在区别。

第四,是否以构成侵权为适用条件不同。侵权损害赔偿请求权的适用前提是行为人的行为已经构成侵权;而人格权请求权的功能在于维护权利人对其人格利益的圆满支配状态,其适用并不需要行为人的行为已经构成侵权。我国民法典之所以需要规定

^② L. Enneccerus/H. Lehmann, Recht der Schuldverhältnisse, Tübingen, 15. Aufl., 1958, S. 1008f.





人格权请求权,是因为人格权请求权的适用不以构成侵权为前提,在保护人格权方面具有独特的功能。例如,有关新闻媒体、网站所刊载的报道内容失实或有明显错误,侵害他人人格权的,权利人有权要求新闻媒体、网站及时更正。上述情形中并不一定要求行为人的行为构成侵权,也不要求权利人必须证明行为人的行为应当承担侵权责任。

第五,是否适用诉讼时效不同。侵权损害赔偿之债作为一种债的关系,应当适用诉讼时效制度,也就是说,如果权利人没有在时效期间内主张权利,债务人将享有时效利益,可以基于此对权利人履行债务的请求提出抗辩。当然,除损害赔偿责任,许多责任形式也难以适用诉讼时效。例如,就停止侵害、排除妨害等责任形式而言,由于相关的侵害行为处于持续状态,因此难以适用诉讼时效制度。对此,我国《民法总则》第 196 条第 1 项也规定,“请求停止侵害、排除妨碍、消除危险”的请求权不适用诉讼时效,此处所说的“请求停止侵害、排除妨碍、消除危险”的请求权本身也是人格权请求权的主要内容。关于人格权请求权是否适用诉讼时效,存在一定争议。民法典草案一审稿第 778 条第 2 款规定“民事主体依照前款规定提出的停止侵害、排除妨碍、消除危险、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉请求权不受诉讼时效的限制。”草案作出此种规定的主要理由在于,一方面,人格权请求权作为一种绝对权请求权属性的权利,本身不应受到诉讼时效的限制。在人格权受到妨害或者可能受到妨害的情形下,权利人应当有权随时提出请求,以恢复权利人对人格利益的圆满支配状态,因此该请求权不应受到诉讼时效的限制。人格权请求权的功能在于保护民事主体对其人格利益的圆满支配,只要该圆满支配的状态受到不当影响,权利人即有权主张人格权请求权。只要对人格权的侵害和妨碍仍处于持续状态,则权利人即应当享有人格权请求权,以消除相应的不利影响。而且从保护权利人的角度出发,只要权利人能举证证明其人格权处于受到妨害或者可能受到妨害的状态,则其就应当享有人格权请求权,该权利不应受诉讼时效的限制。另一方面,我国《民法总则》第 196 条第 1 项规定,“请求停止侵害、排除妨碍、消除危险”的请求权不适用诉讼时效,而停止侵害、排除妨碍、消除危险本身也是人格权请求权的主要内容,在这些情形下,由于行为人的行为一直处于持续状态,诉讼时效无法确定起算点,因此,不应适用诉讼时效。以生命权、健康权为例,只要侵害或者妨碍生命权、健康权的行为一直持续,则权利人即应当有权主张人格权请求权。

正是因为人格权请求权与侵权损害赔偿请求权存有如前所述的不同,因此,有必要在人格权编中设立专门条文对人格权请求权作出明确规定。

三、充分有效保护人格权是 人格权请求权与侵权损害赔偿请求权分离的目的

人格权以维护人之尊严为其核心价值,充分有效保护人格权是现代民法的重要价



论人格权请求权与侵权损害赔偿请求权的分离

值目标,也是我国民法典编纂所要达到的基本目标之一。^{②①} 正如前述,人格权请求权与侵权损害赔偿请求权存在本质差异,单靠后者来保护人格权,不仅不能实现充分有效保护,反而会削弱对人格权的保护。为了充分有效保护人格权,人格权请求权必须与侵权损害赔偿请求权分离。

(一) 弥补现行法在人格权保护制度方面的不足

如前所述,我国现行立法所采取的“吸收模式”在保护人格权等权利方面具有其独特性,但由于其没有区分侵权损害赔偿请求权与人格权请求权,难以适应人格权保护的特别需要。侵权损害赔偿请求权一般适用过错责任原则,要求受害人不仅要证明行为入具有过错,而且要证明自己的损害,还必须证明行为人的行为构成侵权。而在人格权的行使受到妨害时,权利人往往会遇到各种举证困难。例如,在行为入无正当理由拒绝权利人的名称和姓名的变更请求、行为入无正当理由拒绝对简称进行保护、征信机构收集的信用信息不准确但拒绝更正等情形下,要求权利人证明自己遭受了现实的损害,并证明行为人的行为已经构成侵权,确实是十分困难的。此外,人格权请求权不适用诉讼时效,但在“吸收模式”之下,难以解释为何某些类型的侵权责任不适用诉讼时效。

而通过人格权请求权与侵权损害赔偿请求权的分离,既可进一步明确请求权的逻辑体系,又能更充分有效地保护人格权,前文提及的域外经验也验证了这一点。针对人格权保护的特别性,就人格权的保护设置与物权请求权相类似的人格权请求权,该请求权的行使并不要求行为人的行为构成侵权,只要其可能侵害人格权,影响人格权的实现,权利人即可提出人格权请求权,且不受诉讼时效限制,显然更有利于人格权的保护,也可以使权利保护的规则更加精细化。

(二) 强化对人格权侵害的有效预防

人格权请求权具有突出的损害预防的功能,主要原因在于:一是在出现妨害而没有造成实际损害后果的情形下,可以通过人格权请求权对权利人提供救济,这就有利于及时防止损害后果的发生和扩大;二是在行使人格权请求权时,权利人不需要证明自身的损害和行为人的过错,即使是在没有构成侵权的情形下,只要有可能将要造成对人格权的侵害,权利人也可以主张人格权请求权,预防未来发生损害;三是人格权请求权的一些责任形式,如停止侵害、排除妨害、消除危险等,与作为事后救济受害人的责任形式(即损害赔偿)相比较,本身具有强烈的预防损害发生的功能。正如德国学者拉伦茨所指出的,人格权请求权的内容具有特别性,即司法实践在人格权有受到侵害之虞时,准许权利人请求消除危险;在继续受到侵害时,准许权利人请求停止侵害;^{②②}四是人格权请求权的各种表现形式,如更正、撤回、删除、补充、回应等,都具有预防损害发生的功能和作用,人格权请求权之所以应当与侵权损害赔偿请求权相分离,正是为了适应现

^{②①} 沈春耀在《关于〈民法典各分编(草案)〉的说明》中指出“全国人大常委会法工委研究认为,人格权是民事主体对其特定的人格利益享有的权利,关系到每个人的人格尊严,是民事主体最基本、最重要的权利。保护人格权、维护人格尊严,是我国法治建设的重要任务。”《民法典分编草案首次提请审议》,载《人民日报》2018年8月28日第06版。

^{②②} 参见前引②, [德] 卡尔·拉伦茨书,第169-170页。



代社会发展对侵害人格权行为进行预防的特殊需求。

在互联网、大数据时代,强化对侵害人格权损害后果的预防更加重要。网络技术在给我们带来极大便利的同时,也给我们的生活带来了一些负面影响。与传统社会的信息传播方式不同,网络信息的传播具有即时性,而且网络的无边界性以及受众的无限性,也使得网络环境对信息的传播具有一种无限放大效应,网络信息一经发布,可以瞬间实现全球范围的传播。在网络环境下,侵害人格权的损害后果具有不可逆性,损害一旦发生,即难以恢复原状。网络环境下损害后果的易扩散性,也使得人格权,特别是名誉、隐私、肖像、姓名等精神性人格权,在现代社会显得十分脆弱,极易遭受侵害^{②③}。这些都使得网络侵害人格权的行为具有易发性、其损害后果具有不可逆性。考虑到人格权在遭受侵害后,很难恢复原状,因此,就人格权保护而言,应当更加重视对损害后果的预防。但“吸收模式”并不是专门针对人格权保护而设计的,而是针对所有权益受侵害的情形,所以,其无法满足人格权保护在损害预防方面的特殊需要。

如前所述,德国、法国、日本等大陆法国家都在司法实践中,基于人格权请求权的作用而强化了其预防功能,从而使之与侵权损害赔偿请求权相分离。在我国司法实践中,有的法院也基于现代社会发展的需求,于相关的人格权纠纷中,在侵权责任承担方式之外运用了预防性的救济方式。例如,在著名的“钱钟书书信案”中,北京市第二中级人民法院在充分考虑该案对隐私权可能造成的侵害后,准确地作出了司法禁令,禁止被告从事拍卖书信的行为,既有效保护了著作权人权利,又保护了原告的隐私权。^{②④}可见,虽然我国立法主要通过侵权法规则保护人格权,没有单独规定人格权请求权,但从司法实践来看,人格权纠纷的解决并非只能按照侵权处理,在人格权可能遭受侵害的情形下,也可能通过人格权请求权对权利人进行救济。

(三) 有利于法律规则的准确适用和裁判的统一

我国《侵权责任法》第 15 条统一规定各种责任承担方式,似乎各种责任承担方式的适用条件是相同的,而没有必要区分不同侵权责任形式的适用条件。这就导致“吸收模式”在适用中存在一个突出问题,即极易使法官产生一种误解,即所有侵权责任承担方式的适用要件都是相同的,都必须构成侵权才能适用,且权利人需要证明行为人有过错,甚至也不考虑在时效方面是否存在区别,这就不利于一些责任形式的准确适用。但事实上,人格权请求权与侵权损害赔偿请求权在构成要件、诉讼时效的适用等方面存在差异。例如,就停止侵害而言,作为侵权责任承担方式的停止侵害请求权,其适用以行为人构成侵权为前提;而作为人格权请求权的停止侵害,其适用并不要求行为人构成侵权。采取人格权请求权与侵权损害赔偿请求权相分离的模式,将人格权请求权单独规定,进而与侵权损害赔偿请求权相区分,有助于明确两种请求权构成要件的不同,避免混淆,更有利于法官的适用。

^{②③} See Kenneth C. Creech, *Electronic Media Law Regulation*, 5th Edition, at 288 (Elsevier, Focal Press, 2007).

^{②④} 参见《钱钟书书信案引出新民法首例诉前禁令》,载《法制日报》2014 年 2 月 26 日第 5 版。





论人格权请求权与侵权损害赔偿请求权的分离

采取人格权请求权与侵权损害赔偿请求权相分离的模式,有利于实现“同案同判”,维护司法裁判的统一。我国《侵权责任法》虽然规定了各种责任形式,但并没有规定各项责任形式的适用条件,这就可能导致司法裁判的不统一。从司法实践来看,就排除妨碍、消除危险的法律适用而言,有的法院要求原告证明被告有过错,有的法院并未作此要求。以信用权纠纷为例,针对个人的信用记录不实造成个人损害的案件,有的法院认为行为人构成对权利人名誉权的侵害且具有过错,应当承担删除不良信用记录、张贴书面道歉声明、送达书面道歉说明等责任;^⑤而有的法院则认为,“商业银行应当遵守中国人民银行发布的个人信用数据库标准及其有关要求,准确、完整、及时地向个人信用数据库报送个人信用信息”,行为人将权利人的相关信用信息报送至中国人民银行征信中心时未能做到准确、及时、完整,构成对权利人名誉权的侵害,应当予以消除,^⑥但法院在认定行为人构成对权利人名誉权的侵害并应当承担消除相关不良影响后果的责任时,并没有提及是否要求行为人具有过错。必须看到,司法实践中的同案不同判,会严重损害法律的权威性。所以,在立法时将人格权请求权独立出来,明确其适用并不要求满足过错要件,也不需要当事人证明行为人是否具有过错,这也有利于统一司法裁判。

(四) 有效应对现代社会发展中出现的人格权保护的新问题

人格权是不断发展的权利,随着经济社会发展,人格权的类型也日益丰富,而人格权请求权与人格权有不可分性,人格权作为绝对权的发展,必然导致人格权请求权的发展。将人格权请求权与侵权损害赔偿请求权分离,能更好地适应人格权发展的新趋势,解决人格权保护的新问题。具体说来,随着人格权的变化发展,人格权请求权出现了其独立存在的新局面:一是广泛采用停止侵害的方式,预防侵害人格权行为的发生。例如,如果相关出版、发行的作品可能侵害他人的人格权,则在最终判决作出之前,法官还可以作出预先裁决,责令行为人停止出版、禁止发行流通,或责令将出版物全部或部分予以查禁^⑦;二是请求撤回声明权利的行使。所谓撤回,是指在侵害名誉的情形,将侵害人所作的陈述撤回。在德国,近几十年来,司法实践在《德国民法典》第1004条所规定的物权请求权的基础上发展出了撤回请求权(Widerrufsanspruch),此种请求权具有一定的独立性,旨在保护权利人的名誉。^⑧按照德国通说见解,撤回属于排除妨害的一种具体情形,其以侵害行为具有违法性为要件,以侵害人有故意或过失为前提;^⑨三是发展了补充、更正等请求权。例如,欧盟《一般数据保护条例》(GDPR)第17条规定的更正权、删除权等,很大程度上都是人格权保护请求权的具体表现形式。

^⑤ 参见河南省高级人民法院(2015)豫法立二民申字第00159号民事裁定书。

^⑥ 参见山西省临汾市中级人民法院(2015)临民终字第1209号民事判决书。

^⑦ 参见[奥]赫尔穆特·考茨欧、亚历山大·瓦齐莱克《针对大众媒体侵害人格权的保护:各种制度与实践》,匡敦校、余佳楠等译,中国法制出版社2013年版,第170页。

^⑧ Vgl. BeckOGK/Spohnheimer BGB, Aufl., 2017, § 1004 Rn. 14. 司法实践在适用该请求权时有时直接适用第1004条,有时类推适用第1004条,有时直接适用1004条和第823条,有时又类推适用第823条和第1004条,虽然路径不一,但结果基本一致,即不要求行为人具有过错。Vgl. BeckOGK/Spohnheimer BGB, Aufl., 2017, § 1004 Rn. 326.

^⑨ 参见前引^③,王泽鉴书,第431页。





另外,人格权请求权在一定程度上也能促成新型人格权的生成和发展,即一旦立法规定了人格权请求权,法官就可以依据这一制度,促进人格权本身的发展,促成新类型人格权的形成。例如,我国现行立法并没有对声音的保护作出规定,但通过人格权请求权的适用,声音的保护也逐渐得到认可,并可能最终成为一种新型人格权。在瑞士,由 Tercier 教授主持的人格权立法草案的理由报告中也指出,“人格的范围不能也不应该以严格的方式去界定。应该交由法官根据社会观念和对人格的各种危害的变化,来逐渐填补其内容。”^⑩所以,未来一旦我国在人格权法中规定了人格权请求权,法官就可以援引这些规则,来丰富和发展人格权的类型,强化对人格权的保护。

四、人格权请求权可适用于未构成侵权的情形是 其与侵权损害赔偿请求权相分离的重要表现

民法典之所以要承认人格权请求权,并使其与侵权损害赔偿请求权相分离,一方面是因为其具有较为宽泛的适用范围,在侵害人格权的情形下,如果尚未造成实际的损害(包括财产损失和精神损害),或者即便有损害但权利人要主张损害赔偿之外的责任形式,权利人都可以主张人格权请求权;另一方面,人格权请求权不仅可以适用于侵权的情形,而且在妨害人格权的情形下,即便没有构成侵权,也可以适用。由于侵权责任形式必须以构成侵权为适用前提,这就决定了《侵权责任法》不能完全包含人格权请求权。

诚然,我国《侵权责任法》将停止侵害、排除妨碍等作为其责任形式,似乎意味着只有构成侵权才能适用这些责任形式,如果未构成侵权,则不能适用。笔者认为,在未承认独立的人格权请求权时,这种理解是正确的,但是如果承认独立的人格权请求权,将停止侵害等责任形式纳入其中,则这种理解就未必准确。因为在适用人格权请求权的情形下,未必一定以行为人为构成侵权为前提。例如,受害人基于人格权请求权要求行为人为停止侵害,其并不需要证明行为人具有过错或者造成了实际损害,从这一意义上说,人格权请求权的适用并不当然以行为人为构成侵权为前提。

人格权请求权之所以可适用于未构成侵权的情形,主要原因在于:

第一,人格权请求权的效力作用决定了其可适用于未构成侵权的情形。如前所述,人格权具有积极效力和消极效力两个方面。人格权与其他绝对权一样,有积极行使的功能,积极效力是指人格权所具有的支配、控制、依法利用等权能。消极效力是指人格权受到侵害或可能受到侵害时,权利人享有的保护其权利的权能,即所谓的排他效力。基于人格权请求权的效力,当人格权受到侵害或者有受侵害之虞时,权利人即有权主张人格权请求权。例如,在权利人的姓名变更请求权被无理拒绝、征信机构记载的信用记录有误、行为人对他人实施轻微性骚扰等情形下,虽然无法确定行为人是否构成侵权,但只要权利人的权利行使有障碍,就可以主动行使人格权请求权,以消除障碍。

^⑩ 前引⑤,石佳友文。





第二,人格权请求权所具有的维持人格权圆满支配状态的功能决定了其可适用于未构成侵权的情形。侵害财产权大多可以通过金钱赔偿而恢复原状,侵权损害赔偿请求权的目的则是为了填补损害。而侵害人格权的损害后果往往具有不可逆转性(如隐私一旦公开就无法恢复原状),所以,需要更多地强调对损害的预防,即需要通过停止侵害、恢复名誉、消除影响等方式为人格权提供救济。人格权请求权的功能在于维持权利人对其人格权的圆满支配状态,只要行为人不当妨害了权利人对其人格利益的圆满支配状态,即便不构成侵权,权利人也可以主张人格权请求权。例如,信息控制者所收集、公开的个人信息不准确,权利人请求其及时更正时,并不需要证明信息控制者构成侵权。

第三,人格权请求权预防功能的发挥也决定了其可适用于未构成侵权的情形。人格权请求权是直接针对侵害人格权的行为所采取的预防和保护措施,权利人在主张人格权请求权时,并不需要证明行为人具有过错,也不需要证明自己遭受了现实的损害,只要人格权的行使或权利人对其人格利益的圆满支配状态受到了不当影响,权利人均可以主张人格权请求权,以积极主动地保护人格权、预防侵害人格权的行为。由于人格权请求权可以适用于不构成侵权的情形,因此,并不需要通过法院确定行为人是否构成侵权,而可以直接向行为人提出请求,这就更有利于对人格权的救济。由于人格权请求权可适用于未构成侵权的情形,可以将损害预防的时间提前,更有利于及时制止侵害人格权的行为。

尤其应当看到,人格权请求权形式的多样化决定了其可以针对各种妨害人格权的行为行使,而不仅仅针对已构成侵权行为的侵害人格权的情形。如前述,人格权请求权的发展已呈现出多种形式,而我国有关现行立法也适应了人格权请求权的这一发展趋势,对相关的人格权请求权作出了规定。民法典草案一审稿在总结这一经验的基础上,也对多种形式的人格权请求权作出了规定,具体而言,人格权请求权适用于未构成侵权的情形包括:

一是更正权的行使。所谓更正权,是指报刊、网络等媒体刊载的报道内容失实或有关信息控制者记载、公开的信息有误,侵害他人人格权益的,受害人有权请求该媒体或信息控制者及时更正。从比较法上看,许多国家的新闻法,如法国、丹麦、芬兰、泰国以及塞内加尔等,都对更正与答辩权作出了规定。^①在德国法中,在人格权保护(尤其是名誉权的保护)的司法实践中,大量采用了更正请求权(Berichtigungsanspruch)和撤回请求权(Widerrufsanspruch)。正如一些德国学者所指出的,更正请求权系非财产性请求权,但与不作为请求权指向未来的不法行为不同,更正请求权指向的是在过去已经出现且还在持续的妨害。^②我国《网络安全法》第43条对更正权作出了规定“个人发现网络运营者违反法律、行政法规的规定或者双方的约定收集、使用其个人信息的,有权要求

^① 参见《法国新闻自由法》第2章第2节、《丹麦新闻法》第9、10条、《芬兰新闻自由法》第25条、《泰国新闻法》第40-43条、《塞内加尔新闻刊物和记者职业法》第1篇第3章第3节。

^② Vgl. Götting/Schertz/Seitz, Handbuch Persönlichkeitsrecht, C. H. Beck, 2008, § 49 Rn. 4 f.





网络运营者删除其个人信息;发现网络运营者收集、存储的其个人信息有错误的,有权要求网络运营者予以更正。网络运营者应当采取措施予以删除或者更正。”国务院《出版管理条例》第 27 条也对更正与答辩权作出了规定“出版物的内容不真实或者不公正,致使公民、法人或者其他组织的合法权益受到侵害的,其出版单位应当公开更正,消除影响,并依法承担其他民事责任。报纸、期刊发表的作品内容不真实或者不公正,致使公民、法人或者其他组织的合法权益受到侵害的,当事人有权要求有关出版单位更正或者答辩,有关出版单位应当在其近期出版的报纸、期刊上予以发表;拒绝发表的,当事人可以向人民法院提起诉讼。”我国民法典分编草案虽然没有规定更正与答辩权,但就信息控制者在发布信息方面的义务作出了规定。一是征信机构对他人的信用评价发生错误,权利人有权要求更正。民法典草案一审稿第 808 条规定“民事主体可以依法查询自己的信用评价;发现信用评价错误或者侵害自己合法权益的,有权提出异议并要求采取更正、删除等必要措施。信用评价人应及时核查,经核查属实的,应当及时采取必要措施。”二是信息持有人收集的他人信息发生错误,权利人有权请求更正。民法典草案一审稿第 815 条第 1 款规定“自然人可以向信息持有人依法查阅、抄录或者复制其个人信息;发现信息有错误的,有权提出异议并要求及时采取更正等必要措施。”依据该条规定,只要权利人发现信息有错误,就有权请求及时更正。三是信息收集人、持有人有确保信息安全的义务,其中也包括了允许权利人及时查询、更正相关信息的权利。民法典草案一审稿第 817 条第 2 款对此作出了规定。在行使更正权的情形下,权利人并不需要证明侵权发生,也不需要证明其已遭受现实的损害,而只需要证明有错误,即可行使这一权利,尤其是不需要证明信息的收集者、控制者、发布者存在过错,即使被请求人没有过错,其也应当及时更正。

二是删除权的行使。所谓删除权,是指在信息的收集发生错误,或者信息收集的目的已经达到等情形下,权利人有权请求相关的信息收集者、持有者及时清除相关的信息。从比较法上来看,许多国家承认了权利人的删除权。例如,德国联邦宪法法院在“人口普查案”中创设了“个人信息自主权”,即主体对自己信息的控制、知悉、查阅、修改和删除的权利^③;欧盟 GDPR 第 17 条也承认该项权利。我国《网络安全法》第 43 条在更正权之外也规定了删除权。依据该条规定,只要网络运营者非法收集、使用、储存个人信息,权利人均可要求网络运营者更正、删除相关的个人信息,权利人更正权、删除权的行使并不需要网络运营者的行为构成侵权,也不要求权利人必须通过诉讼的方式向网络运营者提出更正、删除的请求。我国其他相关立法也对信息主体的删除权作出了规定,例如,《征信业管理条例》第 16 条第 1 款规定“征信机构对个人不良信息的保存期限,自不良行为或者事件终止之日起为 5 年;超过 5 年的,应当予以删除。”民法典草案一审稿第 815 条第 2 款在总结上述规定的基础上,进一步规定“有下列情形之一的,自然人可以请求信息持有人及时删除其个人信息:(一)存在非法收集、使用信息的行

^③ 参见《德国联邦宪法法院裁判选辑》(一),萧文生译,《司法周刊》1995 年版,第 288-384 页。



为; (二) 持有侵害自然人合法权益的信息; (三) 持有的信息储存期限依法已经届满; (四) 根据收集或者使用的特定目的, 信息持有人持有信息已经没有必要; (五) 其他没有正当理由继续持有信息的情形。”这就进一步确认了信息主体的删除权。删除权的行使不以构成侵权为必要, 权利人在行使删除权时, 无须证明其遭受了现实的损害, 也不需要证明信息的收集者、持有者具有过错。

三是回应权(droit de réponse)的行使。所谓回应权, 是指当有关报刊、网络等媒体披露、报道的信息包含直接涉及他人名誉的事实时, 权利人有权请求该媒体及时采取合理的方式免费发布其针对相关事实的必要回应。例如, 某人在网上披露某明星通过签订“阴阳合同”的方式偷税漏税, 该明星如果认为披露的事实有误, 则其有权请求该网站刊载其回应的文章, 以澄清事实。一方面, 法律规定回应权有利于及时更正有关信息、消除不良影响, 因为其可使媒体受众在较短时间内获取当事人的正反陈述, 从而及时消除不实报道的影响; 另一方面, 回应权制度有助于及时解决纠纷,^⑤ 因为通过回应的方式更正信息能够有助于快速解决纠纷, 而不再需要借助诉讼途径予以解决。从这个意义上讲, 回应权具有预防损害发生的功能, 而且与损害赔偿等责任承担方式相比, 回应权对于恢复受害人良好的声誉可能更为有效。^⑥ 从比较法上看, 回应权最早由法国在1822年的《新闻法》中予以确立, 其被称为“反驳权制度”, 该制度被许多国家立法和判例所采纳。例如, 1983年修订的《瑞士民法典》在第28g-28l条规定了“回应权制度”, 并明确规定了回应权的成立条件, 依照规定, 当参加政府的公共讨论时, 对于忠于事实的报道, 如果当事人也参加了讨论, 则回应权不能成立。同时, 瑞士法还对回应权的行使规则作出了细化规定, 如规定当事人只能通过简洁的方式针对有异议的事实进行回应, 如果当事人的回应违背事实、违反法律或者公序良俗, 则相关媒体有权拒绝其回应请求。^⑦ 德国司法实践也承认了回应权制度。^⑧ 此外, 依据《汉堡新闻法》第11条的规定, 如果相关主体受到新闻报道的影响, 不论其是个人还是机构, 均应当享有回应权。^⑨ 在我国, 前述《出版管理条例》第27条第2款中规定的“答辩”, 其实就是回应, 从该条规定来看, 回应权的行使以权利人合法权益受到侵害为要件, 但从有效保护权利人的人格权出发, 只要权利人认为事实有误, 为了澄清事实, 其就有权作出回应, 而不需要证明行为人的行为已构成侵权, 也不需要证明自身遭受了一定的损害。遗憾的是, 我国民法典草案一审稿人格权编并没有对回应权作出规定, 笔者认为, 我国民法典有必要明确规定回应权。在行使回应权时, 权利人只需提出初步证据证明行为人报道的事实有误, 并不需要证明行为人有过错以及造成实际损害, 就可以在相关媒体上作出回应。

^⑤ Vgl. Kerpen, Das Internationale Privatrecht der Persönlichkeitsrechtsverletzungen – Ein Untersuchung Aufrechtsvergleichender Grundage, 2003, S. 134.

^⑥ See Neethling, JM Potgieter & PJ Visser, *Neethling's law of personality*, at 221 (LexisNexis South Africa, 2005).

^⑦ 参见 [日] 五十岚清《人格权法》, [日] 铃木贤、葛敏译, 北京大学出版社2009年版, 第214页。

^⑧ Vgl. Rüdiger Klüber, *Persönlichkeitsrechtsschutz und Kommerzialisierung*, Tübingen, 2007, S. 118.

^⑨ 参见新羽《域外回应权制度及其启示》, 载《中共南京市委党校学报》2013年第3期。



上述权利的行使是人格权请求权行使的具体体现,彰显了人格权的效力。正是因为上述权利的行使不需要权利人证明行为人为人构成侵权,由此也表明,人格权请求权可适用于未构成侵权的情形,因而,侵权请求权不能完全涵盖人格权请求权,这也是人格权请求权应当与侵权损害赔偿请求权相分离的重要原因。

五、民法典草案关于人格权请求权与侵权损害赔偿请求权分离的立法选择

如前所述,我国《侵权责任法》采纳了“吸收模式”,以侵权请求权涵盖人格权请求权,这一模式的优点在于,在侵权发生之后,可以为受害人提供多元化的救济方式,可以由受害人自由选择,因而有利于对受害人的充分救济。从这一意义出发,笔者曾将其称为公民维权的“百宝囊”。但“吸收模式”并非一种精细化的权利保护模式,尤其是对于人格权保护而言,因其没有区分侵权与非侵权,以及人格权请求权与侵权损害赔偿请求权所具有的不同构成要件和时效适用的情形,无法实现对人格权的精细化保护,因而有必要对“吸收模式”进行必要的改造。

笔者认为,即使在民法典人格权编规定人格权请求权后,仍然应当保留《侵权责任法》所确立的“大侵权模式”。我国民法典草案一审稿第 946 条规定“侵权行为危及他人人身、财产安全的,被侵权人有权请求侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任。”从该条规定来看,民法典草案一审稿仍然保留了停止侵害等预防性的责任形式,这在一定程度上也延续了《侵权责任法》所确立的“大侵权模式”。之所以需要保留这一模式,是因为《侵权责任法》保护的极为宽泛,依据《侵权责任法》第 2 条的规定,除绝对权外,《侵权责任法》还保护股权、继承权等各种民事权益,而且随着社会的发展,除人格权、物权、知识产权外,将来还有可能出现新型的绝对权益,在这些绝对权益遭受侵害的情形下,都需要借助多元化的责任方式予以救济。从这个意义上讲,即便人格权请求权与侵权损害赔偿请求权发生了分离,但侵权责任编中关于侵权责任的预防性承担方式的规定仍然具有兜底性。

但在保留“大侵权模式”的前提下,必须采纳“分离模式”,使人格权请求权与侵权损害赔偿请求权发生分离,使侵权责任编的规则聚焦于侵权损害赔偿。《侵权责任法》第二章所规定的“责任构成和责任方式”应当改为“责任构成和损害赔偿”,也就是说,侵权责任编虽然仍然保留“大侵权模式”,但其规则主要围绕侵权损害赔偿责任而展开。换言之,侵权责任主要是对已经造成的实际损害的救济,而对其他侵权行为,如妨害、正在进行的侵害和危险等,可以适用人格权请求权等绝对权请求权。

事实上,我国民法典草案一审稿在侵权责任编中已经区分了损害和侵害,且主要是以损害赔偿为中心构建责任体系。一方面,该草案已经将原《侵权责任法》第 6 条第 1





论人格权请求权与侵权损害赔偿请求权的分离

款中的“侵害”改为“损害”，^③这实际上是将过错归责原则界定为损害的归责原则，而不是所有绝对权遭受侵害的不利后果的归责原则。因为在妨害、危险以及正在持续的侵害还没有造成实际的损害后果，或者虽然发生了一定的后果，但损害仍在持续的情形下，不能适用过错责任，而应当适用严格责任，且不能计算时效，因此不能适用《侵权责任法》的过错责任原则，这也说明有必要规定独立的人格权请求权。侵权责任编的此种修改虽然只是一字之差的改动，但实际上是对归责原则适用范围的重新界定。《侵权责任法》的过错责任原则应当聚焦于损害，而损害之外的绝对权遭受的妨害等不利后果，则应当交由绝对权请求权予以调整。这也为人格权请求权与侵权损害赔偿请求权的区分提供了有力支撑。另一方面，侵权责任编中的多个条款都强调了造成损害应承担侵权责任。尤其应当看到，民法典草案一审稿在人格权编和物权编中分别规定了人格权请求权和物权请求权，使这两项请求权与侵权损害赔偿请求权发生了分离，此种立法模式符合我国现行立法的做法，值得肯定。

总之，未来侵权责任编仍然需要保留“大侵权模式”，但就人格权保护而言，将要区分侵权损害赔偿请求权与人格权请求权。笔者认为，准确适用两种请求权应当注意如下问题：

（一）区分损害和妨害的不同情形，分别适用人格权请求权和侵权损害赔偿请求权

在人格权受到侵害或者妨害的情形，究竟应当适用人格权请求权还是侵权损害赔偿请求权，需要明确两个请求权制度各自的适用范围。原则上来说，人格权受到妨害（或持续的侵害）或可能受到妨害时，应当适用人格权请求权；而人格权受到侵害并且造成了损害时，就应当适用侵权损害赔偿请求权。这里的关键就是要区分妨害和损害，为人格权请求权和侵权损害赔偿请求权寻找各自的适用领域。从德国法的经验来看，德国学界通过一系列的判决扩张适用了《德国民法典》第1004条的规定。^④该条规定于民法物权编之中，其原本的规范意旨仅仅是为了排除物权人（特别是所有权人）行使物上权利的障碍，但为了填补人格权益保护的需要，德国法院通过类推的方式，将第1004条的适用范围扩张到了保护人格权益（特别是一般人格权）的情况中。具体来说，在损害名誉、侵害肖像以及公开个人隐私之类的情况中，法院都会通过适用第1004条而非传统的第823条以下，来制止和排除对于人格权益的现实的和正在发生的侵害。^⑤排除妨害请求权解决的是为了将来而排除损害源（Schadenquelle）或妨害源（Störungsquelle）的问题，而不是赔偿已经造成的损害，其所适用的是严格责任，而非过错责任。

这一域外经验给我们的启示在于，可以通过区分损害和妨害，而分别适用侵权损害赔偿请求权和人格权请求权。所谓损害，是指因侵权行为而造成受害人的不利益，此种不利益往往可以通过金钱价值予以评价，所以，可以通过“差额说”予以估算，并对受害

^③ 《侵权责任法》第6条第1款规定“行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。”“民法典草案一审稿”第944条第1款规定“行为人因过错损害他人民事权益，应当承担侵权责任。”

^④ Vgl. G. Wagner, FS Medicus, 2009, S. 589ff.

^⑤ Vgl. MüKoBGB/Baldus BGB, § 1004 Rn. 35.





人提供准确的救济^⑫；而妨害行为常常无法用金钱价值予以衡量，其表现为对受害人绝对权的圆满支配状态构成持续性的干涉。损害是已经现实发生的、客观存在的，受害人请求行为人承担损害赔偿责任时，应当证明损害的具体程度和数额，否则可能难以获得救济；而妨害则是正在持续的侵害状态，其最终损害的具体程度和数额尚不确定，还没有形成最终的结果状态。损害是已经结束的侵害状态；而妨害不一定造成实际的损害后果，它是一种持续性的不利影响，是正在进行、尚未结束的一种侵害状态。通常，在造成损害的情形下，可以纳入侵权损害赔偿请求权予以救济；而在单纯构成妨害的情形下，由于并未造成实际的损害，只可以适用人格权请求权。

区分侵权损害赔偿请求权与人格权请求权等绝对权请求权的关键在于，将损害与妨害进行必要的区分。由于损害和妨害的分离是客观存在的，也决定了人格权请求权与侵权损害赔偿请求权的分离是必要的，而且是可行的。就人格权保护而言，将妨害作为人格权请求权的救济对象是十分必要的，因为在人格权受妨害侵害的情形下，权利人往往难以证明其客观上遭受了何种实际损失，此时，允许权利人主张人格权请求权，以除去其遭受的妨害，具有十分重要的意义。例如，在行为人在自己创作的作品上擅自写上他人的姓名，擅自将他人的语音合成演讲视频，擅自对他人肖像进行商业利用等情形下，相关权利人往往难以证明自身遭受了何种实际损害。因此，凡是因侵权行为致他人损害的情形，应当统一适用侵权损害赔偿请求权，而损害之外的其他妨害，则应当分别适用各种绝对权请求权。正如德国一些学者所指出的，侵权损害赔偿请求权以补偿功能（Kompensationsfunktion）为主要功能，妨碍排除请求权更强调预防功能（Präventionsfunktion），一般不具有补偿功能。^⑬

在区分侵权损害赔偿请求权与人格权请求权的模式下，准确适用人格权请求权与侵权损害赔偿请求权，需要区分损害和妨害的不同存在情形，具体而言：

一是妨害和损害并存。在人格权既受到妨害又受到侵害并导致损害的情形，仅仅适用人格权请求权，不能对损害提供救济，还必须要适用侵权损害赔偿请求权，因为侵权损害赔偿请求权旨在对受害人提供事后的救济，而人格权请求权则侧重于对受害人提供事前的预防。此时，将发生人格权请求权和侵权损害赔偿请求权的聚合。这就是说，权利人既可以主张侵权损害赔偿请求权，又可以主张人格权请求权。例如，某人在网络上非法披露他人隐私，受害人既遭受了损害，又因信息仍然存在于网络上而受到了对其人格权的妨害。虽然从表面上看，权利人既要主张人格权请求权，又要主张侵权损害赔偿请求权，似乎比较繁琐，不如原有“吸收模式”简便，但这是法律科学性和法律准确适用的必然要求。在既有损害又有妨害的情形下，适用“吸收模式”可能产生一定的问题：如果对损害和妨害都不要求行为人具有过错，则可能不当妨害行为自由；反之，如果都要求行为人具有过错，则可能不利于人格权益的保护。因此，在妨害和损害并存

^⑫ 参见前引^⑮，程啸书，第 217 页。

^⑬ Vgl. Staudinger/Karl-Heinz Gursky BGB, Aufl. ,2012, § 1004 Rn. 139; Pfeiffer, a. a. O. , S. 8 f.





论人格权请求权与侵权损害赔偿请求权的分离

时,应当综合考虑责任形式的适用。例如,在“马华林诉沈立波模仿其字体制作铭牌并署其名侵犯姓名权纠纷案”中,被告模仿原告的字体为学校做铜字铭牌,并署了原告的姓名,法院认为,该行为构成对原告姓名权的侵害,被告应当承担赔礼道歉、消除影响的责任,并赔偿原告的财产损失。^④ 笔者认为,对此种情形,在民法典人格权编规定人格权请求权之后,对妨害应当适用人格权请求权,而对受害人所遭受的损害,则应当适用侵权损害赔偿请求权。

二是仅有损害而无妨害。在仅有损害而无妨害的情形下,通过侵权损害赔偿请求权已经足以对权利人提供救济,此时,也就没有必要再行使人格权请求权。例如,被告驾驶机动车导致受害人受伤,就属于仅有损害而无妨害的情形,此时,侵权损害赔偿请求权已经足以对权利人提供救济,权利人无权再主张人格权请求权。例如,在“吴某、张某某生命权、健康权、身体权纠纷案”中,吴某侵害张某某的身体,致张某某的健康及精神遭受损害,法院判决被告应当赔偿原告的损失。^⑤ 在该案中,权利人仅遭受损害而未遭受妨害,此种情形下,侵权损害赔偿请求权已经足以对权利人提供充分救济,权利人无权再主张人格权请求权。

三是仅有妨害而无损害。在此种情况下,权利人的人格权只是受到一定的妨害,而未遭受现实的损害,此时,通过人格权请求权已经足以对权利人提供救济。例如,行为人将他人的隐私非法制作成视频,即将在网上发布,受害人知道后要求立即停止。在此情形下,权利人的人格权只是受到一定的妨害,此时,人格权请求权就已经足以对权利人提供充分的救济,由于权利人并没有遭受现实的损害,因此,其无权主张侵权损害赔偿请求权。例如,在“文某诉张某隐私权纠纷案”中,被告作为小区业委会副主任,擅自在小区业主微信群中公告原告起诉小区业委会的信息,并在微信群内发布了原告起诉小区业委会的起诉书,其中包括了原告的姓名、住址、身份证号、电话等隐私内容,法院认为,被告侵害了原告的隐私权,应当承担排除妨害、删除帖子、赔礼道歉等责任,但原告无法证明自身遭受了严重的精神损害后果,因此无权主张精神损害赔偿。^⑥ 笔者认为,本案中,原告仅遭受了妨害,并未遭受现实的损害,在我国民法典规定人格权请求权之后,权利人主张人格权请求权就已足以救济其权利,而无需再主张侵权损害赔偿请求权。

人格权请求权所对应的责任承担方式具有显著的多样性,^⑦重点救济对人格权益的妨害,但在行为人侵害他人人格权造成权利人损害的情形下,人格权请求权难以为权利人的损害提供有效救济,而应当交由侵权损害赔偿请求权提供救济;侵权责任则主要聚焦于损害,侧重于救济现实的损害。即便侵权责任编对停止侵害等预防性的责任承担方式作出了规定,而且某些人格权请求权在形式上似乎是一些预防性的责任形式的具体化,也不宜将人格权请求权与此类预防性的责任承担方式的关系认定为特别法与一

^④ 参见最高人民法院中国应用法学研究所编《人民法院案例选》(民事卷6),人民法院出版社2017年版,第3152页。

^⑤ 参见河南省郑州市中级人民法院(2018)豫01民终6899号民事判决书。

^⑥ 参见北京市昌平区人民法院(2017)京0114民初15482号民事判决书。

^⑦ Vgl. Jauernig/Teichmann BGB(Fn. 12) .





般法的关系。因为,一方面,人格权请求权是绝对权的保护方式,在性质上不同于侵权责任承担方式;另一方面,某些人格权请求权是一些人格权所特有的保护方式,无法被预防性的侵权责任承担方式所涵盖。此外,人格权请求权的适用并不需要行为人的行为构成侵权,而对预防性的侵权责任承担方式而言,其适用以行为人构成侵权为前提。

在人格权请求权与侵权损害赔偿请求权分离之后,我国民事立法中就会形成完整的绝对权请求权体系,这就是由物权请求权、人格权请求权和知识产权请求权组成的体系。绝对权请求权与侵权损害赔偿请求权相分离,将使我国民法权利保障制度更加完善。

(二) 区分侵害行为是否持续且是否产生损害后果

如果侵害人格权的行为已经终结,并产生了实际的损害后果,此时,主要应当适用侵权损害赔偿请求权对受害人提供救济。但如果侵害行为处于持续状态,尚未产生实际损害后果,或者损害后果难以判断,此时,应当通过人格权请求权对权利人提供救济。需要指出的是,由于人格权请求权是一种概括性的权利,在适用时必须注重具体情形,并根据不同情形来准确适用人格权请求权,只有这样,才能实现其充分有效保护人格权的功能。例如,针对可能发生的妨害,要考虑不同情形而分别适用人格权请求权。正如王泽鉴教授所指出的,“第一次侵害后,其后有侵害之虞,得为推定。对生命、身体、健康、自由(如绑架)的侵害之虞应从宽认定。对名誉、隐私(包括姓名、肖像)等的侵害,多涉及言论自由,事先干预应更审慎。”^{④⑧}

(三) 区分是否针对侵权诉讼而适用

区分损害和妨害的不同情形,有利于界分两种请求权的适用条件。侵权损害赔偿请求权以造成损害为前提,以行为人具有过错为要件。而人格权请求权则并不要求受害人证明自身损害,也不需要证明行为人具有过错,正是因为这一原因,该项请求权的行使并不需要行为人的行为构成侵权,也不需要权利人必须通过诉讼的方式行使权利。

需要指出的是,虽然人格权请求权可以在诉讼外行使,但与侵权损害赔偿请求权类似,权利人在行使人格权请求权时,也应当负有容忍轻微妨害的义务。因为任何人都必须容忍来自他人的轻微妨害,以维护社会安定及人与人之间的和睦、团结。正如冯·巴尔教授所指出的,人格权保护必须基于侵害的非轻微性,否则不得行使人格权之排除妨害请求权,排斥他人的轻微妨害。此外,权利人在提出请求权以后,如果相对人具有正当的抗辩事由,如相对人是在正当地行使新闻自由等权利,那么其也可以阻止权利人人格权请求权的行使。因此,人格权请求权的行使也应当遵循诚实信用原则和公平原则,对于轻微的妨害,权利人应当予以容忍。

(四) 充分尊重当事人对请求权的选择

虽然应区分损害和妨害的不同情形而适用不同的请求权,但具体如何适用,则应当根据私法自治原则,尊重当事人对请求权的选择。在人格权请求权与停止侵害、排除妨碍等预防性的侵权责任承担方式并存的情形下,行为人侵害他人人格权时,权利人能否

^{④⑧} 前引⑬,王泽鉴书,第390页。





论人格权请求权与侵权损害赔偿请求权的分离

同时主张人格权请求权与侵权损害赔偿请求权? 此时究竟发生请求权的竞合还是聚合? 笔者认为,此种情形应当构成请求权的竞合而非聚合,权利人有权选择主张人格权请求权或者侵权损害赔偿请求权,按照私法自治原则,依据何种请求权提出请求,应当由权利人自由选择,法官也应当尊重当事人的选择。当然,在权利人选择依据侵权请求权提出请求时,其应当举证证明行为人构成侵权,而且应当通过诉讼的方式主张权利,从这一意义上说,主张人格权请求权对权利人人格权的救济更为有利。

结 语

王泽鉴教授指出“人格权是构成法秩序的基石。”^④设置独立的人格权编突出了人格权保护的重要价值,是对民法典体系的重大完善,也是保障人民美好幸福生活的重要内容。我国民法典草案已经设置了独立成编的人格权,但有关人格权请求权与侵权损害赔偿请求权的关系,在理论界还存在许多模糊认识,不从理论上加以澄清,会影响对人格权编的正确理解和适用。因此,只有在综合既有理论、实践发展和域外法律经验的基础上,科学论证人格权请求权与侵权损害赔偿请求权的分离,才能为人格权编提供坚实的理论基础,也才有助于对人格权编的正确理解和准确适用。

Abstract: The independent compilation of personality right is a great innovation of Chinese Civil Code. The significant and difficult problems that need to be solved by the legislation of personality right in China are whether the right to claim personality right should be stipulated in the personality right law with independent compilation and how to stipulate the right to claim personality right. The author believes that the independence of the right to claim personality right is the basis of its separation from the right to claim for damages, and the emergence and development of the right to claim personality right is an important development trend of the system of personality right. The difference between the right to claim personality right and the right to claim damages is the reason for their separation, and the effective protection of personality right is the purpose of separating the right to claim personality right from the right to claim damages. The author also discusses the legislative choice of separation mode of the right to claim personality right and the right to claim damages in the draft of Civil Code.

(责任编辑:任彦)

^④ 前引^③,王泽鉴书,第1页。

